

1502687-85.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502687-85.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502687-85.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - AS9785-1/2021 - 2º Distrito Policial de Guarulhos, AS9785-1/2021 - 2º Distrito Policial de Guarulhos, 2285543 - 02º D.P. GUARULHOS, 2361/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO SANTANA DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ROGERIO SANTANA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado por infração ao disposto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 6h39min, na Avenida Emílio Ribas, n.º 2345, Jardim Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante escalada, com rompimento de obstáculo, 21 metros de cabos elétricos, avaliados em R\$ 150,00, de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos, conforme auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 17/18 e laudos periciais a serem juntados (fls. 70/71).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/60).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fls. 72/73).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 86/87) e apresentou resposta à acusação, com

rol de testemunhas comuns (fls. 91/92).

Em 13 de janeiro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 107/110).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 17 de março de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunha Anderson Lopes de Abreu (GCM) e Luiz Claudio Gomes da Costa (GCM). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 139/143).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, a pena-base poderá ser acima do mínimo legal, dada a personalidade do agente, voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. Ademais, o réu danificou o semáforo, deixando-o sem funcionar, o que trouxe prejuízos à sociedade. Na segunda fase, deve incidir a confissão, ainda que feita de forma qualificada. Na terceira fase, ausentes questões a serem consideradas. O regime deverá ser o semiaberto, devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §2º e §3º do Código Penal. Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como o sursis. É o caso de prisão preventiva, pois o réu está cometendo diversos crimes em liberdade (fls. 140/141).

A defesa de ROGÉRIO, por seu turno, preliminarmente, requereu a declaração da ilicitude das provas obtidas pelos guardas civis municipais, nos termos do artigo 157 do CPP e do artigo 5º, LVI, da CF. No mérito, ante o frágil conjunto probatório colhido, requereu a improcedência da ação penal, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, por cautela, requereu: sejam afastadas ambas as qualificadoras; seja reconhecido o furto de pequeno valor com a aplicação exclusiva da pena de multa ou, subsidiariamente, com a redução da reprimenda em 2/3 (dois terços); seja fixada a pena no mínimo legal; seja considerada a atenuante da confissão espontânea; seja fixado o regime prisional aberto para o cumprimento da reprimenda corporal; seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. Por fim, postulou a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, porque o acusado é pobre na acepção jurídica do termo e se encontra patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 141/143).

Após a juntadas das folhas de antecedentes criminais (fls. 149/156), o Ministério Público reiterou as alegações finais já ofertadas, assinalando quanto a presença dos maus antecedentes e reincidência do acusado, a ensejar o início do cumprimento de pena em regime mais gravoso (fl. 167). A defesa do acusado, por seu turno, reiterou as alegações apresentadas e pontuou que a reincidência não é específica, de modo que não impede a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 168).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A preliminar de ilicitude da prova, baseada no argumento da ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal, não merece guarida a alegação da defesa, eis que os guardas tem uma atuação secundária, na medida em que cabe aos guardas municipais a defesa da população local, compreendida na repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, responderiam na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, dado que têm o dever de agir, posto que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além do que, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de segurança o dever legal. Desta forma, é conferida à Guarda Municipal, sempre civil, a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Vasta é a jurisprudência nesse sentido, aqui a do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA. PRECEDENTES. [...]2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, §8º, CF), bem como qualquer um do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP). [...]"(STJ HC 290.371/SP 5ª Turma Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.2014 DJe 30.05.2014);

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE.1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei processual penal, em momento algum, exige que policiais civis ou militares sejam acionados para que dêem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a prisão, como aventado na impetração. Precedentes. [...]"(STJ - RHC 45.173/SP 5ª Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. 06.05.2014 DJe 14.05.2014);

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, §8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...]"(STJ - HC 109.105/SP 5ª Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.2010 DJe 22.03.2010).

No mais, recentemente foi sancionada a Lei n.º 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Segundo este dispositivo constitucional, as Guardas Municipais devem ser disciplinadas por meio de lei. A Lei n. 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratarem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais.

A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei n.º 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas

também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social. Pode-se destacar, por exemplo, que são competências específicas das Guardas Municipais:

"Art. 5º [...]

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento."

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei n.º

13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Superada tal questão, NO MÉRITO, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fls. 17/18), laudo pericial de exame de peça - mochila (fls. 83/85), laudo pericial de levantamento local de furto, constatação de escalada e ruptura de fios (fls. 63/67 repetido às fls. 99/103), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado ROGÉRIO, senão vejamos.

O acusado ROGERIO SANTANA DOS SANTOS, em solo policial, alegou que subiu em um poste, e começou a puxar o fios, quando logo em seguida, os guardas civis chegaram. Iria vender os fios, sendo que é paga a quantia de R\$ 2,00 com casca no fio, e R\$ 6,00 sem casca. Informou não ter nenhum familiar ou pessoa conhecida para informar sobre sua prisão. Informa ter recebido uma cópia de sua nota de culpa (fls. 14). Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Admitiu ter subtraídos os fios, porém, negou a escala, bem como o corte dos fios. Disse que os fios já estavam cortados, contudo, ainda amarrados ao poste. Usou a faca para cortar o enforca-gato que prendia os fio. Já foi processado anteriormente. Disse que ficou preso nos Estados do Pará, Brasília e Rio de Janeiro, além de já responder outros processos no Estado de São Paulo.

Os guardas civis municipais ANDERSON LOPES DE ABREU e LUIZ CLAUDIO GOMES DA COSTA, em solo policial, em depoimentos semelhantes narram que são integrantes da VTR 679, informam que via central de rádio, tomaram ciência de que havia uma pessoa, aparentemente, com transtornos psicológicos subindo em um poste do semáforo. Assim,

diligenciaram ao local indicado, onde constataram que o semáforo estava apagado e, indagado alguns populares pelo local, os mesmos informaram que havia um indivíduo furtando os fios elétricos do semáforo, e teria se evadido do local, tendo os populares, passado as características do indivíduo furtador, bem como, indicado a direção em que tal indivíduo, havia se evadido. Diante de tal informação, os guardas diligenciaram na direção informado, onde pela Rua Diogo Botelho, altura do número 312, avistaram um indivíduo, com as mesmas características passadas anteriormente, trazendo consigo, uma mochila, ocasião em que abordaram o indivíduo. Assim, o indivíduo foi identificado como sendo Rogério Santana dos Santos, ora maior de idade, onde foi feita revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, foi feita revista no interior da mochila que Rogério carregava, onde foi encontrado aproximadamente 21 metros de fios elétricos. Indagado Rogério sobre tais fios, confessou que subiu em um poste, e utilizou-se de uma faca de cortar pão, na cor branca, para cortar os fios. Informam os guardas civis que, em razão da informação de Rogério, de que teria se valido de uma faca, diligenciaram nas proximidades da abordagem, onde encontraram uma faca, com as mesmas características indicadas por Rogério. Assim, após a detenção, Rogério indicou aos guardas civis, o local em que subiu, e pegou os cabos, onde então, os guardas civis, retornaram ao local, onde constataram a ruptura de fios do semáforo. Ante os fatos, os guardas civis, entraram em contato com a central, onde foi feito contato com um representante da Secretaria de Trânsito responsável pelo semáforo, onde compareceu a delegacia, a pessoa de Gilson Janeiro de Paula, Técnico em semaforização, funcionário da Prefeitura de Guarulhos. Diante dos fatos, conduziram Rogério a delegacia, para adoção das medidas de polícia judiciária (fls. 09/12). Em juízo, o guarda civil municipal ANDERSON LOPES DE ABREU disse que foram solicitados pelo rádio para averiguar denúncia de um indivíduo que estaria subindo no poste do semáforo. Ao chegar, não havia mais ninguém no local, porém constataram que havia fios caídos e o semáforo não estava funcionando. Testemunhas indicaram a direção que o rapaz teria seguido. Duas quadras após encontraram o denunciado. Com o rapaz foi apreendido uma mochila com os fios subtraídos. O rapaz teria indicado o local onde teria dispensado a faca usada para cortar os fios, a qual foi localizada na via pública. Questionado, o rapaz confessou a subtração dos fios. Disse que o semáforo era padrão, com cerca de quatro a cinco metros de altura. Não acionaram a polícia militar ao chegar no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil municipal LUIZ CLAUDIO GOMES DA COSTA, o qual, em juízo, disse que estava na base quando tomou conhecimento de que tinha um indivíduo furtando fios do poste/semáforo. Foram ao local, mas a pessoa já tinha saído. O semáforo estava com fios rompidos e não estava funcionando.

Populares apontaram a direção que o rapaz havia tomado. Não muito a frente, o rapaz foi abordado. Com ele apreenderam uma mochila com os fios subtraídos. Questionado, o indivíduo confessou que estava furtando os fios. Acredita que a faca apreendida também estava na mochila. Informou que o poste em que o réu teria subido para subtrair os fios tinha cerca de dois metros. Reconheceu o acusado entre outros dois presos exibidos, como sendo a pessoa detida na ocasião.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários dos guardas civis pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão do acusado, ainda que parcial, acrescida dos depoimentos dos guardas civis municipais, bem como do fato do acusado ter sido detido ainda próximo ao local, em poder da fiação subtraída, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a autoria delitiva que lhe está sendo imputada, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

Nota-se, ainda, que os guardas civis municipais mostraram-se firmes e seguros ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

De outra banda, o fato do réu ROGÉRIO ter sido surpreendido na posse dos cabos elétricos de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos, reforça a procedência da acusação, mormente porque não justificada a posse do bem.

Nessa esteira: "a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo da licitude ou, ao menos, que não tinha condições de depreender tal circunstância" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0775642-41.2009.8.26.0577, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado 20-10-2015).

Além da prova da materialidade e autoria delitiva, bem como do dolo do agente, presente a qualificadora da escalada, diante declarações dos guardas municipais ao atestarem que, para subtrair os fios, o acusado escalou um poste de semáforo, o que evidencia que era de altura superior à altura média de um homem adulto, bem como conclui-se que o réu teve de empregar esforço acima do comum.

O laudo pericial de levantamento local de furto, constatação de escalada e ruptura de fios retratou o local dos fatos e que os cabos elétricos do semáforo foram rompidos e dependurados (fls. 63/67 repetido às fls. 99/103).

O fato do laudo pericial não ter apontado a altura semáforo, não afasta a configuração da qualificadora, pois a prova oral é suficiente para evidenciar o esforço anormal realizado pelo acusado para a prática delitiva, como no caso dos autos.

Já quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que esta deve ser afastada, uma vez que o cabo de borracha que envolve os fios não consiste em obstáculo à subtração, mas visa proteger os fios da chuva.

O crime se consumou. Sabidamente no crime de furto se adota a teoria do amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva, sendo absolutamente dispensável a posse mansa e pacífica. No caso em apreço, o réu foi abordado em local diversos dos fatos, pelos guardas municipais que foram acionados por testemunhas, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso

repetitivo (Tema 934), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012.” (REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Noutro vértice, é de se ressaltar que não prevalece a tese defensiva de atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não se há falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De fato, na linha da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359-RS/MG, Rel^a. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC n. 143.304/DF, Rel^a. Ministra Laurita Vaz, DJe 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), a alegação de pequeno valor da res furtiva, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor.

No caso em tela, verifica-se que, apesar de ser de pequeno valor a res furtiva (21 metros de cabos elétricos, avaliados em R\$ 150,00), mostra-se incompatível, destaque-se, com o princípio da insignificância, a conduta ora apurada, uma vez que o denunciado é reincidente (F.A. de fls. 150/156), o que, de plano, já impede a aplicação do mencionado princípio, porquanto haveria forte incentivo à prática criminosa reiterada, com o consequente desrespeito ao fundamento da pena, que é exatamente a ressocialização do agente.

Com efeito, a jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior de Justiça entende não ser possível a aplicação do princípio da insignificância em caso de agente reincidente, possuidor de maus antecedentes, que reitera no mundo do crime e demonstra habitualidade delitiva. A propósito, confira-se alguns julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEISA DESCONSTITUIRA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente, possuidor de maus antecedentes, que reitera no mundo do crime e demonstra habitualidade delitiva, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 603.539/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe

20/10/2020) (Grifei);

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Como dito no decisum reprochado, é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é reincidente específico na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.463.296 - MG (2019/0069288-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) (Grifei);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - É inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.420.946/GO, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/2019 (Grifei);

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO-FISCAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que a habitualidade delitiva denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Processos administrativo-fiscais podem demonstrar a contumácia do agente, não representando ofensa à Súmula 444/STJ. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp n. 1.753.727/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/2/2019);

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte possuem o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente reincidente em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta. Agravo desprovido" (AgRg no HC n. 448.437/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 1º/08/2018) (Grifei);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à possibilidade de reconhecimento da bagatela ante a constatação da reincidência. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/08/2018) (Grifei);

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.040.868/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/8/2017);

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO BAGATELAR. 1. Não se aplica a insignificância em crimes de furto, como ocorre na espécie, quando o autor do delito, não somente seja reincidente específico, mas quando tem também reiterados envolvimento em delitos deste jaez. 2. Agravo regimental improvido" (AgRg no RESp n. 1.683.320/RS, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/8/2017) (Grifei);

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. [...] II - Ademais, na linha da jurisprudência desta eg. Corte, ressaltado o meu entendimento pessoal, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada, haja vista que o agravante é reincidente (precedentes). Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp n. 1.683.364/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25/9/2017) (Grifei).

Diante do pequeno valor do bem subtraído, o que poderia se defender era a aplicação do privilégio, todavia, considerando que o acusado é reincidente, não há que se falar na incidência do artigo 155, §2º, do Código Penal, como requerido pela nobre defesa.

Preenchidos, portanto, todos os requisitos legais, é de rigor a condenação do acusado por delito de furto qualificado consumado.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado ROGÉRIO, pelo delito de furto consumado qualificado pela escalda, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo a dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que o réu praticou o crime nas condições normais previstas no tipo penal (sua condenação será considerada na segunda fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea. Presente, ainda a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, eis que o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado (processo n.º 0100863-63.2017.8.19.0001, da 4ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, cuja punibilidade foi julgada extinta pelo cumprimento da pena em 13/11/2018, conforme F.A. de fls. 150/156), sendo, portanto, reincidente. Assim, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mantenho a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas diminuição e de aumento de pena a serem observadas, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em 2 (dois) anos de

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena e reincidência do réu, fixo regime inicial SEMIABERTO.

No mais, a despeito da reincidência, considerando que esta não é específica, e levando em conta que o acusado já está preso a tempo superior a metade da pena fixada, entendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

Diante da aplicação de penas alternativas, reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ROGERIO SANTANA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, substituído por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA